

1500991-79.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500991-79.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/000863

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180968/2022 - 04º D.P. PIRACICABA, 25944191 - 04º D.P. PIRACICABA, 2180968 - 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATEUS CORREA SOARES

Réu Preso

Aos 06 de dezembro de 2022, às 14:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dr. DENIS PEIXOTO PARRON - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: MATEUS CORREA SOARES - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC HERALDES JOSE CALLOVI - AUSENTE

Testemunha comum: PC RUBENS LOPES BATISTA - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: DEBORA STEFANE DE SOUZA LARA - AUSENTE

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha PC RUBENS LOPES BATISTA.

Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, por ele foi dito que desistia das oitivas das testemunhas PC HERALDES JOSE CALLOVI e DEBORA STEFANE DE SOUZA LARA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia das oitivas das testemunhas PC HERALDES JOSE CALLOVI e DEBORA STEFANE DE SOUZA LARA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu MATEUS CORREA SOARES foi devidamente interrogado. O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito o seguinte: "Autos n.º 1500991-79.2022.8.26.0599 MATEUS CORREA SOARES está sendo processado como como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Feito regularmente processado. Procede a ação penal. DOS FATOS Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de julho de 2022, por volta de 09h30min, na Rua Humberto Dabronzo, n.246, bairro Algodoal, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, MATEUS CORREA SOARES, qualificado e indiciado às fls. 21-22, guardava e tinha em depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 34 (trinta e quatro) eppendorfs contendo crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 2,6g (dois gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, policiais civis foram até a residência do denunciado para cumprir mandado judicial de busca e apreensão de possíveis objetos furtados (fls. 55-58). Porém, no quarto do denunciado, dentro de um invólucro de pastilhas, encontraram as drogas acima descritas e R\$75,00 (setenta e cinco reais). Aos policiais e na delegacia de polícia, o denunciado assumiu a propriedade da droga, mas disse que era para uso próprio (fls. 21-21). Também na delegacia de polícia, Débora Stefâne De Souza Lara, companheira do denunciado, disse que ele vende drogas no bairro Algodoal (fls. 05). Diante das circunstâncias, apreensão de considerável quantidade de porções embaladas para a venda e a informação de que o denunciado vende drogas no bairro Algodoal, é certo que ele guardava e tinha em depósito entorpecente para o fim de comércio ilícito. Auto de exibição e apreensão de fls. 14-15 e laudo pericial de fls. 18-20 E 133-135. DA PROVA NA FASE JUDICIAL Rubens Lopes Batista - policial civil - narrou que foi cumprir mandado de busca na casa do réu, suspeito de um furto de uma televisão e outros objetos. Na casa da mãe dele, ele se mostrou muito nervoso. No quarto, o outro policial encontrou um tubo de chocolates "MM" com entorpecentes e dinheiro. De início, ele negou responsabilidade. Na Delegacia, a namorada do réu disse que ele vendia entorpecentes. Depois, ele mesmo confessou. Não o conhecia. O quarto de quem foi encontrado o entorpecente era da mãe do réu, mas ela tinha cedido para ele dormir aquela noite com a namorada. O réu confessou que vendia e que era dele a droga. Heraldes Jose Callovi - policial civil, no mesmo sentido quando ouvido na fase policial. Débora Stefâne de Souza Lara - confirmou na fase policial que o réu vendia substâncias entorpecentes. Interrogado, o réu disse que sua mãe tinha cedido o quarto para ficar com sua companheira. É usuário de crack. Os policiais chegaram com o mandado de busca e apreensão. A droga que tinha era para uso próprio. Mas eram dezenove papéis de crack e não a quantidade que os policiais apresentaram. Pegava bastante para não precisar ir sempre na biqueira. Na delegacia, ficou separado de Debora. Eles lhe fizeram muitas perguntas, mas a droga não era para a venda. Tinha comprado a droga no dia anterior. Usava a droga de madrugada no quarto da casa de sua mãe. Na noite antes de os policiais chegarem, tinha usado cinco porções. Gastou setenta reais para comprar a droga. Cada porção custa cinco reais. Tinha comprado dezenove. Usava dez a quinze porções por dia. Pegava papelão na rua e trabalhava de servente, juntava dinheiro e comprava drogas para usar. Não conhecia os policiais. Negativa do réu ilhada. Nada a corrobora. As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em

13/03/2009). Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: "A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011). Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498). E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10) DA PENA Folha de antecedentes e certidões nos autos: MATEUS CORREA SOARES é reincidente específico (autos 0000313-17.2017.8.26.0599) e portador de maus antecedentes (autos 0010472-56.2009.8.26.0451; 0030399-08.2009.8.26.0451) - fls. 64-68 Pena acima do mínimo legal e regime fechado inicial. Por óbvio, não é possível o Acordo de Não Persecução Penal (CPP, art. 28-A). Não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Também não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Há de se considerar a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos. Ora, as circunstâncias especiais do fato, a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, mais nocivas à saúde e com maior potencial de levar o usuário à dependência devem ser levadas em consideração na dosimetria da pena, servindo-se para afastar o benefício legal acima mencionado. (RT 775/559). É o que permite o artigo 42 da Lei 11.343/06. Vale reforçar que, em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime. Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes. O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar

tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90). O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014). Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06. Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal nos termos da inicial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado, razão pela qual deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Rubens, Policial Civil, declarou que foram cumprir um mandado de busca e apreensão, pois o réu era investigado pela suposta prática de um furto. Quando fizeram as buscas, o réu se mostrou muito nervoso e o colega da testemunha efetuou as diligências no quarto. Em determinado momento, o parceiro da testemunha localizou um tubo de M&M contendo drogas e uma quantidade de dinheiro. Inicialmente, o réu negou a propriedade dos entorpecentes. A namorada do réu, na Delegacia, disse que ele vendia entorpecentes. Não conhecia o réu antes dos fatos. O quarto pertencia à mãe do réu, mas ela cedeu para ele dormir naquela noite, junto com a namorada do acusado. Ela confirmou essa informação. O réu confessou informalmente o tráfico. O réu, em interrogatório, declarou que estava em casa com sua esposa, pois mora com sua mãe. Ela cedeu o quarto para que morasse com a Debora. É usuário de crack e depende da sua mãe. Houve uma denúncia e os Policiais ingressaram no imóvel por conta do mandado. Tinha comprado 19 porções de crack para seu consumo pessoal. Comprou uma porção maior para não ir com frequência ao ponto, por conta de seus antecedentes. Os Policiais queriam saber de uns objetos furtados, mas não tinha nada. Eles também encontraram as drogas e foi levado para a Delegacia. Quando chegou ao local, disse aos Policiais que os entorpecentes não eram para venda. Comprou a droga no dia anterior aos fatos e depois foi para a casa da sua mãe usar os entorpecentes durante a noite. Comprou 19 porções de crack. Usou umas 05 porções durante a noite e pagou cerca de R\$ 70,00 pelas drogas. Cada porção custa cerca de R\$ 5,00. Usava cerca de 10 a 12 porções de crack por dia. Ganha cerca de R\$ 100,00 ou R\$ 150,00. Comprava as drogas juntando papelão, reciclagem, etc. Juntava dinheiro e ia comprar os entorpecentes. Portanto, Excelência, o acusado nega a prática dos fatos. Sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais provas dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável

pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se, pelo próprio depoimento dos Policiais, que nenhum "ato de comércio" foi visualizado antes da abordagem, eis que os agentes, na realidade, investigavam um crime de furto e somente "acharam" as drogas durante as diligências, pois não existiam sequer denúncias prévias apontando o réu como o responsável pelo tráfico na região. Além disso, apesar da apresentação da Senhora Debora, na Delegacia de Polícia, como testemunha presencial da abordagem, seu depoimento não foi confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, os outros familiares do acusado, que não foram apresentados na Delegacia e presenciaram as diligências, sequer foram ouvidos. Ressalte-se, ainda, que a suposta confissão informal do acusado, além de constituir uma circunstância aberrante no ordenamento jurídico, não foi confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas, sendo que, reitere-se, não foi verificado qualquer ato efetivo de mercancia dos entorpecentes. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a

Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminosa), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder

punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFe, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao eu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juízes para a Democracia, 2001). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iii) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ e, ainda, em razão do disposto no art. 387, § 2º, do CPP; (iv) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar

o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva".

Então, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

MATEUS CORREA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 05 de julho de 2022, por volta de 09h30min, na Rua Humberto Dabronzo, nº 246, Bairro Algodoal, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, guardava e tinha em depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 34 (trinta e quatro) "ependorfs" contendo "crack", substância derivada da cocaína, com peso líquido de 2,6g (dois gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que policiais civis foram até a residência do acusado para cumprir mandado judicial de busca e apreensão de possíveis objetos furtados (fls. 55/58). Porém, no quarto do réu, dentro de um invólucro de pastilhas, encontraram as drogas acima descritas e R\$ 75,00 (setenta e cinco reais). Aos policiais e na delegacia de polícia, o acusado assumiu a propriedade da droga, mas disse que era para uso próprio (fls. 21/21). Também na delegacia de polícia, Débora Stefâne de Souza Lara, companheira do réu, disse que ele vende drogas no bairro Algodoal (fls. 05). O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 142) e apresentou defesa preliminar (fls. 146/150), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 151/153).

Designada audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e, após, foi interrogado o acusado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pela fotografia de fls. 16 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 133/135, que trouxe resultado positivo para cocaína.

A autoria também é certa, pois o réu admitiu a propriedade do entorpecente apreendido, em ambas as oportunidades em que foi ouvido.

Resta apurar se a droga se destinava a seu consumo próprio, como alegou o réu, ou de terceiros, como consta da denúncia.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu negou a prática do delito que lhe foi imputado. Disse que já foi preso pela prática de tráfico de drogas. Alegou que trabalhava como servente de pedreiro, porém, na data dos fatos, não estava trabalhando. Afirmou que estava na sua residência com a sua companheira Débora, quando os policiais chegaram informando que tinham uma ordem judicial e começaram a revistar o interior do imóvel. Aduziu que os policiais localizaram dentro do quarto algumas porções de "crack" que lhe pertenciam e se destinavam ao consumo próprio (fls. 21/22).

Em juízo, reiterou sua versão. Asseverou que estava em casa e sua mãe cedeu o quarto de baixo para ele ficar com sua namorada. Afirmou que foi feita uma denúncia e os policiais foram a sua casa para cumprir um mandado de busca. Asseverou que é usuário de drogas e tinha comprado dezenove porções de crack para seu uso. Disse que comprou essa quantidade para evitar ficar indo em biqueiras. Aduziu que sua mãe nem sabia que tinha a droga em casa. Esclareceu que tinha comprado a droga no dia anterior e usou droga durante a noite. Aduziu que usou umas cinco porções antes dos policiais chegarem. Declarou que gastou R\$ 70,00 e cada porção custava cinco reais. Alegou que usava de dez a doze porções de "crack" por dia. Informou que ganhava em torno R\$ 150,00 por mês.

O policial civil Rubens, ouvido em juízo, relatou que foram cumprir mandado de busca, pois Mateus era averiguado de ter furtado TV, notebook e outras coisas.

Asseverou que, quando do cumprimento, ele estava muito nervoso e dava a impressão

de querer fugir. Disse que seu colega fazia buscas e, em determinado momento, informou que achou um tubo de uns dez centímetros de chocolate M&M, entorpecentes e dinheiro. Afirmou que ele negou a prática do crime, falou que o quarto era da mãe. Porém, ele foi levado para a delegacia para ser ouvido até sobre os furtos e confessou a prática do crime. Aduziu que a namorada dele, também conduzida à Delegacia, disse que ele vendia drogas. Atestou que apuraram que o quarto onde encontraram as drogas era da mãe do réu, mas os familiares disseram que ela tinha cedido o quarto para o réu dormir com a namorada.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Heraldes, ouvido a fls. 03.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). De outra banda, Débora, companheira do acusado, ouvida apenas na fase policial, afirmou que, no dia dos fatos, foi acordada pela mãe do réu, a Sra Clotilde, avisando que a polícia estava na casa e estava nos procurando e os objetos produto de furto, no qual o réu e "Nino" tiveram participação. Atestou que, após ver o mandado de busca e apreensão, acompanharam os policiais fazerem tal vistoria e, em determinado momento, eles perguntaram ao réu sobre quatro aparelhos telefônicos celulares e sobre uma caixa de metal de pastilhas Menthos, em cujo interior havia várias porções de entorpecentes (crack) e uma pequena pochete com dinheiro, mas apenas ouviu o réu dizer que não era nada dele. Asseverou que o réu vende drogas no bairro Algodoal, não sabendo dizer para quem e o local exato em que faz esse comércio. Acrescentou que desconhecia que ele tinha guardado a droga e o dinheiro no quarto (fls. 05).

A quantidade de entorpecentes apreendida e a forma como estavam acondicionados, aliados às declarações da companheira do acusado, prestadas na fase policial, revelam que a droga se destinava mesmo ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito o seguinte precedente:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. -

Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Some-se a isso que o acusado não demonstrou ter renda para sustentar vício tão caro.

Ora, ele afirmou que usava de dez a doze porções de "crack" por dia e que cada uma custava R\$ 5,00, mas asseverou que ganhava R\$ 150,00 por mês.

Anoto, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de

traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498). Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente guarde ou tenha em depósito a substância entorpecente.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (autos nº 0030399-08.2009 da 3ª Vara Criminal local - fls. 117/121). Assim, fixo a pena-base, acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

De acordo com o art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência, mas podem ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do mesmo código.

Nesse sentido decisão do C. STJ: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES.

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que à luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência mas podem ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. Considerando que o ordenamento jurídico pátrio adota quanto aos maus antecedentes o sistema da perpetuidade, e não da temporariedade, como no caso da reincidência, é de se manter o entendimento pacificado por este Sodalício de que, mesmo ultrapassado o prazo depurador, as condenações anteriores podem ser consideradas como maus antecedentes. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp nº 1.604.407/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 12.08.2016).

E o STF, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Na segunda fase de fixação de pena, observo que o acusado é reincidente, inclusive específico (autos nº 0000313-17.2017 da 1ª Vara Criminal local e nº 0010472-56.2009 da 2ª Vara Criminal local - fls. 117/121), razão pela qual aumento a pena em um quinto, resultando sete anos de reclusão e seiscentos e noventa e nove dias-multas. Não há circunstâncias atenuantes.

Inexistem causas de aumento e, por ser o réu reincidente, não faz jus à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, por ser o réu reincidente específico e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Comprovada a origem ilícita do dinheiro apreendido, de rigor o perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu MATEUS CORREA SOARES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de sete anos de reclusão e seiscentos e noventa e nove dias-multa, no valor unitário mínimo, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra preso e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 05/12/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]